

1500767-87.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

HEVELEEN HIWRI ELIAS HIRAKAWA e outro

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

HEVELEEN HIWRI ELIAS HIRAKAWA e LUIZ GUSTAVO DOS REIS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500767-87.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000564

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

HEVELEEN HIWRI ELIAS HIRAKAWA e outro

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

HEVELEEN HIWRI ELIAS HIRAKAWA e LUIZ GUSTAVO DOS REIS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 11h20min, na altura do nº 399 da

Rua Odete Garcia, no bairro Cidade Morumbi, nesta cidade e Comarca, teriam sido surpreendidos por policiais militares trazendo com eles e guardando, com a finalidade de vender a terceiros para consumo, 2,08 g (dois gramas e oito centigramas) da droga Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, e 3,66 g (três gramas e sessenta e seis centigramas) da droga cocaína, conforme Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico Toxicológico juntados a fls. 15/17 e 80/82, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que agiam em concurso e com unidade de propósitos.

A ré Heveleen, não localizada para ser notificada pessoalmente (fls. 122), foi notificada por edital (fls. 128).

O acusado Luiz Gustavo foi notificado pessoalmente (fls. 137) e apresentou defesa preliminar (fls. 141).

Posteriormente, a acusada Heveleen foi notificada pessoalmente (fls. 160) e apresentou defesa preliminar (fls. 164/165).

A denúncia foi recebida (fls. 170/171). Não localizada para citação e intimação pessoal (fls. 198), a ré foi citada e intimada da audiência por edital (fls. 204).

O acusado Luiz Gustavo foi pessoalmente citado.

Foi determinado o desmembramento do feito em relação a Heveleen com aproveitamento da prova antecipada em relação a ela.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelo órgão acusador e Defesa dos acusados, e o réu Luiz Gustavo foi interrogado.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena.

A Defesa do réu requereu pena-base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do benefício previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime mais brando para início de cumprimento de pena, com substituição por penas alternativas, especialmente pela primariedade do acusado, além de recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 02/05, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisória de fls. 15/17, laudo de exame químico toxicológico de fls. 195/197, com resultado positivo para cocaína e maconha, bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa em relação ao acusado Luiz Gustavo.

Interrogado na fase policial, ele permaneceu silente.

Em juízo, admitiu o tráfico. Alegou que era dependente químico e que um colega havia vendido sua bicicleta para pegar drogas. Ficou em desespero, pois era o único bem que possuía, e concordou em vender drogas para um desconhecido para poder recuperar sua bicicleta. Era a primeira vez que vendia drogas. Estava junto com Hevelen, que era usuária de drogas e passou a noite no local, sendo que pediu para ela guardar o dinheiro dos entorpecentes que estava vendendo quando foram abordados por policiais.

A confissão do réu está em consonância com a prova dos autos.

Interrogada na fase policial, a acusada Heveleen mencionou ser usuária de cocaína há cerca de seis anos, sendo que faz uso diário desta droga. No dia dos fatos, disse ter ido até a "biqueira" para adquirir drogas, porém, acabou por concordar em ficar guardando dinheiro, até o momento em que foi surpreendida pelos policiais na posse de dinheiro juntamente com outro indivíduo que revendia drogas. A interroganda esclareceu ser portadora de problema de saúde, isto é, um coágulo na cabeça e cordas vocais, razão pela qual faz uso contínuo de medicamentos denominados Gardenal, Depakene e Trileptal. Alegou já ter sido internada para tratamento do vício em drogas por cinco meses na Clínica Nova Esperança, no bairro Torrão de Ouro, nesta cidade, há uns três anos (fls. 18).

A confissão policial da ré Hevelen, inclusive apontando o corréu como o indivíduo que revendia drogas no momento em que ela ficava com o dinheiro arrecadado, está em

consonância com as demais provas dos autos.

Com efeito, os policiais militares Daniel e Fabio, ouvidos nas duas fases do procedimento, narraram que foram acionados via rádio para se dirigirem até a Rua Odete Garcia, esquina com Rua Benedito Batista Campos, bairro Cidade Morumbi, nesta cidade, local conhecido pela revenda ilícita de drogas, para averiguar denúncia de que havia um casal que comercializava drogas e que escondiam o entorpecente em cima de um muro. Ao chegarem ao logradouro indicado, os policiais avistaram o casal cujas características físicas e vestimentas eram condizentes àquelas descritas via COPOM, que foram identificados como os ora acusados Luiz Gustavo e Heveleen. Ao ver a aproximação da viatura, o acusado Luiz Gustavo ocultou algo em seu bolso, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, os policiais apreenderam 03 (três) pinos com cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, além de R\$20,00 (vinte reais) na posse de Luiz Gustavo. Por sua vez, Heveleen tinha consigo R\$210,00 (duzentos e dez reais), apreendidos após busca realizada por uma policial feminina acionada em apoio. Junto ao muro próximo de onde o casal se encontrava, os policiais apreenderam outros 08 (oito) pinos com cocaína, idênticos àqueles apreendidos em poder de Luiz Gustavo, ou seja, eppendorfs de cor vermelha. Indagada, Heveleen admitiu que estava comercializando drogas, assim como Luiz Gustavo (fls. 08/09).

Neste cenário, o tráfico de drogas restou demonstrado em relação ao acusado.

Não foi produzida prova hábil a desconstituir as declarações dos policiais, que visualizaram o acusado em local conhecido pela venda de drogas, na posse de entorpecentes, após o recebimento de denúncia anônima.

Ademais, o acusado, ao ser abordado, admitiu informalmente aos policiais acerca da traficância e confirmou a atividade ilícita em juízo.

Demonstrada, assim, a ocorrência do crime descrito na denúncia e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar as penas a serem impostas.

O réu é primário.

Assim, fixo suas penas no mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso. Com fulcro no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11.343/06, não havendo notícia de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, pois nenhuma prova foi feita neste sentido, reduzo as penas do tráfico em 2/3, fixando-as definitivamente em 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no piso.

Anoto que a redução prevista no dispositivo não é inconstitucional, pois, da mesma forma que a Lei Maior facultou ao legislador ordinário agravar a pena de crimes que considerava hediondos ou graves, retirando de seus autores benefícios que poderiam ser concedidos a autores de delitos de outras espécies, igualmente graves, também permitiu que a reprimenda fosse diminuída em razão de circunstâncias que indicassem o menor potencial lesivo da conduta do agente.

A Constituição Federal, no seu artigo 5.º, XLVI, trata da individualização da pena. Ao distinguir o pequeno traficante dos demais, a norma infraconstitucional apenas atendeu à diretriz da Carta Magna, não havendo qualquer ofensa a ela.

Neste sentido leciona José Celso de Mello Filho ao tratar do citado dispositivo: "a exigência de individualização da pena, que é de índole constitucional, deve ser analisada sob três aspectos principais: a) o da individualização legal, operada pelo legislador, por meio da abstrata cominação das sanções em função da maior ou menor gravidade objetiva do ilícito; b) o da individualização judicial, efetuado pelo magistrado, por meio da sentença, no momento da aplicação concreta da sanção penal; c) o da individualização administrativa, concretizada na fase de execução da pena, ensejando-se, dessa forma, nos estabelecimentos prisionais, um tratamento específico para cada condenado" (Constituição Federal Anotada, 2ª ed. Saraiva 1986).

Não havendo prova de envolvimento anterior do réu com atividade ou organização criminosa, inviável o afastamento da mitigação da pena.

Frise-se que o fato de ter cometido uma conduta de traficância não significa, por si, que se dedique à atividade ou integre organização criminosa, de modo a configurar motivo idôneo para afastar a causa especial de diminuição da pena, tendo em vista que incumbe à acusação demonstrar o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido é a lição Renato Brasileiro de Lima: "(...) quanto ao ônus da prova acerca da presença (ou ausência) dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é certo dizer que, em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, incumbe à acusação comprovar a impossibilidade de aplicação da referida causa de diminuição de pena, demonstrando que o acusado não é primário, não tem bons antecedentes, que se dedica a atividades criminosas ou que integra organização criminosa. Se não o fizer, a dúvida milita em favor do acusado, autorizando a aplicação da minorante. Afinal, como se observa a doutrina, fosse necessário que a defesa provasse os requisitos negativos de não se dedicar a atividade criminosa ou não integrar organização criminosa, haveria evidente violação à presunção de inocência, porquanto a prova negativa indeterminada é daquelas que se pode chamar de prova diabólica, tamanha a dificuldade em se desincumbir dela"

Considerando que, além do réu ser primário e sem antecedentes, o órgão acusador não demonstrou elementos concretos que indiquem que se dedicava ou integrava organização criminosa, a aplicação da causa de diminuição é medida de rigor.

A alegação de que tráfico de entorpecentes ser comandado, via de regra, por organizações criminosas (multinacionais), não implica, necessariamente, que o acusado, flagrado pela primeira e única vez em conduta de traficância, integre tais organizações, porquanto devem ser comprovados os requisitos da estabilidade e da permanência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado LUIZ GUSTAVO DOS REIS ao cumprimento das penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, no HC 118.533, pacificou o entendimento que o tráfico privilegiado não deve ser considerado crime de natureza hedionda.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observo que, de fato, há decisão do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 97.256, que redundou na edição da Resolução nº 05/2012, do Senado Federal, suspendendo a proibição que constava do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 para aplicação da benesse, deixando a matéria ao prudente arbítrio do juiz, que analisará, no caso concreto, sua adequação como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Por conseguinte, revisando o entendimento adotado por esta Magistrada há muitos anos, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e observados os critérios de individualização da pena, vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo o regime inicial aberto, consoante disposto no artigo 33, § 3.º, do Código Penal. Outrossim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I a III, e artigo 77, caput, inciso III, do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade impostas aos réus por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo das penas substituídas, em entidade a ser definida pelo juízo da execução, além da prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade também a ser definida pelo juízo da execução.

Em caso de descumprimento do benefício, deverá iniciar o cumprimento de suas penas no regime aberto.

Poderá o réu recorrer em liberdade em face da pena imposta e porque nesta condição respondeu ao processo.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos em favor do FUNAD, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA